

1504179-29.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO REZENDE MARQUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Vistos.

JULIANO REZENDE MARQUES DA SILVA (RG 43119686/SP) foi denunciado como incurso no art. 33, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504179-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504179-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO REZENDE MARQUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Vistos.

JULIANO REZENDE MARQUES DA SILVA (RG 43119686/SP) foi denunciado como incurso no

art. 33, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 14h50min, na Praça Júlio Prestes, nº 1º, nesta cidade e comarca, teria trazido consigo, para a entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 93,3g (noventa e três gramas e três decigramas) de "Cannabis sativa L" (THC), conhecida por "maconha" e 53,3g (cinquenta e três gramas e três decigramas) de "Cannabis sativa L" (THC), conhecida como maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 4).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (fl. 53/56).

Foi determinada a destruição das drogas apreendidas e mantida a prisão preventiva do acusado (fl. 83).

O acusado foi citado (fl. 98).

A Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fls. 101/102).

A denúncia foi recebida (fl. 104).

Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas policiais. Ao final, o réu foi interrogado.

As partes, então apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No tocante à preliminar de nulidade do interrogatório do réu em relação à suposta violação do artigo 188 do Código de Processo Penal, constato que a mesma não merece prosperar.

Tenho que o interrogatório possui 3 (três) fases: de qualificação, de individualização e de mérito.

Pois bem.

No caso em apreço, o interrogatório colhido em audiência foi gravado pelo sistema audiovisual no SAJ e, de sua análise, é possível observar que este juiz formulou os questionamentos iniciais e, logo em seguida, foi dada oportunidade para as partes indagarem diretamente o acusado, evidenciando proceder imparcial.

Posto isso, não se vislumbra irregularidade alguma. Não se pode desconsiderar que o juiz é o destinatário último da prova, pois a apreciará por ocasião da prolação da sentença, de modo que a lei processual penal faculta-lhe poderes de instrução para a busca da verdade real.

Demais disso, eventual inobservância do tanto quanto previsto no artigo 188 do Código de Processo Penal caracterizaria vício relativo, devendo ser arguido mediante a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte. Em situação análoga já restou decidido: "(...) a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita" (STF - RHC nº 122.467/SP - Segunda Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Julg. 3.6.2014).

Dessa forma, além de se caracterizar como melhor prática processual a forma como foi conduzida a instrução processual, não se comprovou a existência de eventual prejuízo ao acusado.

Embora a violação às formalidades do interrogatório judicial possa constituir nulidade relativa para uns e absoluta para outros, o STF tem exigido a demonstração do prejuízo para qualquer espécie de nulidade (absoluta ou relativa).

Por fim, de se registrar que o interrogatório é meio de defesa, de modo que o réu sequer é obrigado a responder a qualquer pergunta que lhe é feita. Ou seja, mesmo que perguntado sobre os fatos pelo magistrado, o acusado poderá permanecer em silêncio, de modo que em nenhuma hipótese este silêncio poderia ser levado em seu desfavor no momento de o juiz proferir a sentença.

Dessa forma, REJEITO a preliminar aventada.

No tocante à nulidade da prova tendo em vista que o encontro dos entorpecentes foi realizado por guardas municipais, não comporta acolhimento a tese defensiva.

Como visto, a abordagem do acusado foi precedida de fundadas suspeitas, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes públicos

que conduziram a diligência.

Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem, havendo motivação legítima para a abordagem.

Nesse sentido, confira-se:

"TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. 2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior. 3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente." (STJ, HC 552.395/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/3/2020).

Portanto, considera-se lícita a prova derivada da busca pessoal, com base na existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos do § 2º, do art. 240 do Código de Processo Penal.

Ademais, se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, com maior razão não há falar-se em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão.

Em que pesem as atribuições elencadas nos parágrafos do artigo 144 da Constituição Federal, o caput deste dispositivo estabelece que a segurança é responsabilidade de todos, de modo que qualquer do povo tem o poder de dar voz de prisão em flagrante delito.

Passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de prisão em flagrante (fl. 4), o auto de exibição/apreensão (fl. 16/17), laudos periciais (fls. 93/95 e 161/163), bem como pelas provas orais abaixo transcritas.

A testemunha guarda municipal Jilcimar da Silva Durães afirmou que, junto ao seu parceiro de patrulha, estavam em policiamento fixo pela Praça Júlio Prestes, quando por volta das 14h50min visualizaram um indivíduo vindo da Av. Duque de Caxias e indo em direção ao fluxo e que, ao perceber a presença da equipe, tentou fugir, motivo pelo qual, foram atrás para abordá-lo. Disse que, em busca pessoal do suspeito, identificado como Juliano Rezende Marquis da Silva, foram encontrados, numa sacola, 62 (sessenta e dois) invólucros de substância parecida com maconha, 01 (um) pequeno tablete de substância parecida com maconha e uma balança de precisão. Destacou que, ao ser questionado, Juliano nada disse sobre a droga. Afirmou que, diante disso, deram voz de prisão e o conduziram até o D.P.

A testemunha guarda municipal Igor Fontes Martins declarou que, junto ao seu companheiro de patrulhamento, estavam em policiamento fixo pela Praça Júlio Prestes, quando por volta das 14h50 visualizaram um indivíduo vindo da Av. Duque de Caxias, indo em direção ao fluxo e que, ao perceber a presença da equipe, tentou fugir, motivo pelo qual foram atrás para abordá-lo. Aduziu que, em busca pessoal do suspeito, identificado por Juliano Rezende Marquis da Silva, foram encontrados, numa sacola, 62 (sessenta e dois) invólucros de substância parecida com maconha, 01 (um) pequeno tablete de substância parecida com maconha e uma balança de precisão. O acusado Juliano Rezende Marques da Silva, em seu interrogatório disse que um rapaz lhe ofereceu 20 reais para entrar com a droga em ponto de comércio de entorpecentes.

Diante conjunto probatório formado nos autos, restou comprovada a conduta criminosa imputada ao acusado.

Conforme restou provado, o acusado se encontrava na Praça Júlio Prestes, na região central da cidade de São Paulo, reconhecida pela existência da "crackolândia" em seu entorno. Nesse contexto, ao notar a presença dos guardas municipais, o acusado demonstrou certo nervosismo e tentou empreender fuga. Diante do contexto, os agentes públicos procederam à sua abordagem e revista pessoal.

Em sua posse, foram encontradas 93,3g (noventa e três gramas e três decigramas) de "Cannabis sativa L" (THC), conhecida por "maconha", armazenados em 62 (sessenta e dois) invólucros e mais 53,3g (cinquenta e três gramas e três decigramas) de "Cannabis sativa L" (THC) em forma de tablete, além de uma balança de precisão, conforme se atestou pelos laudos periciais acostados às fls. 93/95 e 161/163. Ante o exposto, comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado ao acusado, é de rigor a condenação.

Passo à injunção da pena.

Fixo a pena base do crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, porque não há elementos que justifiquem seu aumento.

A agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "navrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "navrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "navrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativonº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavirus disease 19 COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público na peça vestibular. Por outro lado, há a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, porquanto o acusado ostenta reincidência, razão pela qual a pena é aumentada em 1/6, devendo inclusive a reincidência prevalecer diante da confissão espontânea do acusado.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição. Cumpre apontar que é inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dada a reincidência do acusado.

Portanto, a pena definitiva será de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixada no patamar mínimo legal.

Deverá o réu cumprir a pena no regime fechado, dada a sua reincidência, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, diante da reincidência específica.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu JULIANO REZENDE MARQUES DA SILVA (RG 43119686/SP) como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime

inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada no patamar mínimo legal.

O réu deverá permanecer preso porque presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública (anotando-se que o fato é relativamente recente, além de ser o réu reincidente a indicar que a probabilidade da prática de novos crimes), além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes e do objeto apreendidos.

P.I.C.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA